

RECURSO CÍVEL Nº 5067913-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUCIA MARTINS PEREIRA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, CF/88. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE ATRASADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ. EDCL NO RESP 1192556/PE - REPETITIVO E RESP 1607418/RS. PARCELA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. ARTIGOS 41, 63 E 76 DA LEI Nº 8.112/90. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, ressaltando apenas que eventual valor pago administrativamente deverá ser compensado do montante global. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2024.

5067913-02.2024.4.02.5101

510014416484 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5067913-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUCIA MARTINS PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pleito autoral, para condenar a ré a incluir na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias a verba recebida pelo autor a título de abono de permanência, bem como a pagar as diferenças decorrentes relativas a parcelas vencidas desde quando devidas, até a data da inatividade, observadas as diretrizes delineadas nos arts. 63 e 76, da Lei nº 8.112/90, obrigando-se, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, a União, inicialmente, requer a suspensão do feito com base nos Temas nº 346 da TNU e 1.233 do STJ. No mérito, alega a impossibilidade de o valor do 13º salário ser superior ao valor da remuneração já integrada pelo abono, e a consequente ofensa aos arts. 7º, VIII, e 201, § 6º, da CF/88, e ao art. 63, *caput*, da Lei 8.112/90. Aduz que na realidade, o servidor com direito ao abono de permanência recebe a gratificação natalina também com o abono, mas em rubrica específica, distinta da rubrica própria do 13º salário. Sustenta a não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias e da consequente impossibilidade de o abono de permanência, que corresponde ao valor do PSS, integrar a base de cálculo do adicional, e da violação ao art. 40, § 19 e ao art. 7º, XVII da Constituição da República e ao art. 3º, § 3º da EC 103/2019. Argumenta, também, no que tange ao aumento de remuneração sem previsão de lei específica e da ofensa ao princípio da separação dos poderes, bem como de eventual violação ao art. 37, X e ao art. 2º da Constituição e à Súmula vinculante 37 do STF. Sustenta a inaplicabilidade da jurisprudência do STJ ao caso em tela. Pugna, portanto, pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, sustenta, em síntese, que o abono de permanência é vantagem pecuniária permanente, integrante da remuneração, de modo que deve ser considerada no cálculo do adicional constitucional de terço de férias e da gratificação natalina, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, entendo que o mesmo não merece prosperar, uma vez que o Tema 346 da TNU não determina qualquer ordem de suspensão, bem como no Tema 1.233 em recursos repetitivos, a ordem de sobrestamento se restringe aos REsps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça.

Passo a adentrar no mérito.

A questão a ser reapreciada diz respeito à natureza jurídica da verba abono de permanência, que se for remuneratória e permanente deverá integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, nos termos pedidos pela parte autora.

O abono de permanência é uma vantagem concedida aos servidores públicos que, tendo condições de se aposentar, optam por permanecer em atividade. Seu valor corresponde exatamente àquele pago pelos servidores na ativa a título de contribuição previdenciária, lançado como estorno no mesmo contracheque cuja contribuição PSS é descontada, correspondendo a uma nítida isenção fiscal previdenciária, porém, com lançamento e concomitante estorno, em vez na simples não incidência do tributo.

Os artigos 63, caput, e 76, caput, da Lei nº 8.112/1990 dispõem que a remuneração do servidor é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, respectivamente. Da análise do artigo 41, caput, da Lei nº 8.112/1990, extrai-se que o conceito de remuneração do servidor público abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Quanto à natureza jurídica da verba abono de permanência, se indenizatória ou remuneratória, o STJ consolidou seu entendimento quando do julgamento de embargos de declaração em recurso especial julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 424) e decidiu que é verba de natureza remuneratória. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Por inexistir fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter o acórdão do Tribunal de origem quanto à questão impugnada no recurso especial, não há falar em incidência da Súmula 126/STJ.

2. Esta Seção manifestou-se sobre a natureza jurídica do abono de permanência, quando prestigiou, no acórdão embargado, o entendimento da Segunda Turma, que, ao julgar o REsp 1.105.814/SC, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, reconheceu a incidência do imposto de renda sobre o aludido abono com base nas seguintes razões de decidir: "O abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado.

Com efeito, é facultado ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. O abono de permanência possui, pois, natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional." (grifou-se). Com efeito, o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito.

3. Verificar se o acórdão embargado enseja contrariedade a normas e princípios positivados na Constituição é matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, alheia ao plano de competência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que para fins de prequestionamento, conforme entendimento da Corte Especial (EDcl nos EDcl nos EREsp 579.833/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 22.10.2007).

4. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp 1192556/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 17/11/2010)

Em sequência, o STJ também tem forte jurisprudência sobre ser o abono de permanência verba permanente, afastando o caráter transitório, posto que somente se extinguirá com a aposentadoria do beneficiário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TRIBUTÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. A orientação da Corte Especial do STJ é no sentido de que, em Execução contra a Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, ou seja, em relação ao montante do valor executado que não foi objeto de Embargos à Execução.

3. Cumpre registrar que, no âmbito federal, a orientação do STJ foi consolidada na Súmula 31/AGU, in verbis: "É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública."

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ele cessará. (grifei).

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório.

6. O mesmo se diga em relação ao auxílio-alimentação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça entende que tal verba, quando paga em dinheiro, possui natureza remuneratória.

7. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1607418/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016)

Ressalte-se que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão sobre a natureza do abono de permanência é de âmbito infraconstitucional (ARE 1273308 / RS - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 27/08/2020; RE 758345 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, DJe em 17/04/2018).

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do Recurso Especial 1192556/PE (Tema 424), segundo a sistemática de recursos repetitivos, fixou que o abono de permanência tem natureza remuneratória (e não indenizatória), ao definir que sobre tal verba incide o Imposto de Renda, o que autoriza o julgamento monocrático do presente recurso.

Assim, não obstante o abono de permanência corresponder apenas a um estorno da contribuição previdenciária, significando um incentivo ao trabalho do servidor e o desonerando no ônus fiscal, a jurisprudência concebeu tal verba como remuneratória e componente da remuneração e desta forma deve ser concebida para todos os efeitos.

Portanto, ainda que o referido julgado tenha sido prolatado para fins de arrecadação tributária, ele repercute sobre o caso em tela, ao definir a natureza jurídica do abono de permanência, devendo ser aplicada para outros fins, qual seja, para se definir se tal verba integra o conceito de remuneração para fins de cálculo de gratificação natalina e terço de férias.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito do caráter "permanente" do abono de permanência, por entender que, uma vez concedido, não pode ser suprimido do pagamento do servidor:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.

1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo.

2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.

3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor.

Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010.

6. “Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada” (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.795.795, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, publicação em DJe de 11/10/2019.) (sem grifos no original)

Portanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são incontroversas a natureza remuneratória e o caráter permanente do abono de permanência, o que o enquadra no conceito de remuneração estabelecido pelo art. 41, caput, da Lei nº 8.112/1990, e impõe a sua integração na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, nos termos dos artigos 63, caput, e 76, caput, da referida nº Lei 8.112/1990.

Precedente, *mutatis mutandis*, da 6ª Turma Recursal (Processo nº 5080130-19.2020.4.02.5101, julgado na Sessão Extraordinária de 10/03/2021, de relatoria da Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE).

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso**, mantendo integralmente a sentença recorrida, ressaltando apenas que eventual valor pago administrativamente deverá ser compensado do montante global. Condene a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.